

1008320-81.2016.8.26.0286

Classe: Ação Civil Pública

Assunto: Improbidade Administrativa

Magistrado: Andrea Leme Luchini

Comarca: Itu

Foro: Foro de Itu

Vara: 1ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 24/05/2022

... pelo exercício nocivo das funções e empregos públicos, pelo "tráfico de influência" nas esferas da Administração Pública e pelo favorecimento de poucos em detrimento dos interesses da sociedade, mediante a concessão de obséquios e privilégios ilícitos. (PAZZAGLINI FILHO, Marino; ELIAS ROSA, Márcio Fernando e FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Improbidade Administrativa, Editora Atlas, 1996, pág. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itu

Foro de Itu

1ª Vara Cível

Rua Luiz Bolognesi, s/n, Itu - SP - cep 13301-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1008320-81.2016.8.26.0286 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1008320-81.2016.8.26.0286

Classe - Assunto

Ação Civil Pública - Improbidade Administrativa

Requerente:

Ministério Público do Estado de São Paulo

Requerido:

Eppo Saneamento Ambiental e Obras Ltda e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Andrea Leme Luchini

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou a presente Ação de Responsabilização por Ato de Improbidade Administrativa e Ressarcimento ao Erário em face de EPP0 Saneamento Ambiental e Obras Ltda, José Carlos Ventri, Marilda Cortijo, Luiz Carlos Lourencetti, Antonio Luiz Carvalho Gomes, Miguel de Moura Silveira Júnior, Beatriz Fernanda Cristofolletti Campregher e Vanessa Daniela Correa.

Em resumo, informa que o Inquérito Civil n. 14.0306.0000754/2016-1 foi instaurado com o objetivo de apurar irregularidades em processo licitatório (n.193/2008), modalidade concorrência pública tipo menor preço (n.06/2008), e contratação de empresa para execução de obras de reforma e ampliação de cinco escolas municipais, por iniciativa da Secretaria de Educação do Município da Estância Turística de Itu.

Segundo consta, sagrou-se vencedora do certame a requerida, Eppo Saneamento Ambiental e Obras Ltda, que firmou o contrato administrativo n. 02/2009. O requerido, Luiz Carlos Lourencetti, então Secretário Municipal de Planejamento, Obras e Serviços Viários, foi designado gestor do contrato e fiscal da execução das obras, sob orientação e aprovação final da Secretária Municipal da Educação, Marilda

Cortijo.

Consta da petição inicial que o Tribunal de Contas do Estado julgou irregulares a licitação e os respectivos contratos. Noticiadas as irregularidades, o Ministério Público instaurou Inquérito Civil e apurou a existência de: a) Irregularidades no edital, falta de planejamento ou de cronograma adequado, aglutinação indevida de objetos, limitação da concorrência com direcionamento em favor da empresa contratada; b) Irregularidades no procedimento licitatório, não observância da melhor proposta, manipulação de preços e valores apresentados pela requerida licitação e os respectivos contratos. Noticiadas as irregularidades, o Ministério Público instaurou Inquérito Civil e apurou a existência de: a) Irregularidades no edital, falta de planejamento ou de cronograma adequado, aglutinação indevida de objetos, limitação da concorrência com direcionamento em favor da empresa contratada; b) Irregularidades no procedimento licitatório, não observância da melhor proposta, manipulação de preços e valores apresentados pela requerida EPP0 em franco prejuízo ao erário, superfaturamentos "mascarados".

O Parquet atribui aos requeridos responsabilidade por irregularidades constatadas na gestão dos contratos, pelos secretários municipais, pelos membros da comissão de licitações, pela requerida, EPP0 e seu sócio-gerente, todos incluídos no polo passivo, individualizadas as condutas na petição inicial e especificadas as respectivas responsabilidades (pgs.60). Enfim, enumerando os atos de improbidade administrativa e quantificando a lesão ao erário, requer a aplicação das sanções cabíveis na espécie, pela prática das condutas enumeradas, e a condenação dos requeridos ao devido ressarcimento ao erário.

Foi determinada a notificação dos requeridos conforme o artigo 17, §7º, da Lei 8.429/92. Seguiram-se as notificações dos requeridos e vieram aos autos as defesas prévias (pgs.1024/1045, pgs.1278/1322).

Recebida a inicial por decisão de pgs.1457/1461, foram rejeitadas as preliminares e determinado o sobrestamento do feito para análise de Tema de Repercussão Geral (nº 897), concernente à imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário, decorrentes de atos de improbidade, pelo Supremo Tribunal Feral.

Retomado o curso da ação, os requeridos foram citados.

MARILDA CORTIJO, LUIZ CARLOS LOURENCETTI, ANTONIO LUIZ CARVALHO GOMES, MIGUEL DE MOURA SILVEIRA JÚNIOR, BEATRIZ FERNANDA CRISTOFOLETTI CAMPREHER e VANESSA DANIELA CORREA apresentaram contestação de pgs.1523/1566. Impugnam o valor atribuído à causa e a estimativa de danos supostamente oriundos de sua conduta. Alegam preliminar de prescrição uma vez que os atos ocorreram no período entre outubro de 2008 e dezembro de 2009, superando o lapso de 6 anos. No mérito, sustentam que as provas são frágeis, insuficientes à comprovação da prática de ato ímprobo. Rebatem a assertiva de que não houve o planejamento adequado para a execução das obras de reforma, manutenção e ampliação. Sustentam que, no caso em análise, era recomendável que as obras fossem objeto de um único processo licitatório eis que todas visavam à adequação dos prédios de escolas integrantes da rede pública municipal, por meio de reforma ou de ampliação. Argumentam que a falta de cronograma não impactou no andamento das obras, sendo que o tempo suplementar para a conclusão não ultrapassou 4 meses. Negam ter havido limitação de concorrência ou qualquer direcionamento, defendem a regularidade dos atos praticados pela comissão de licitações e sustentam que o acréscimo contratual não ultrapassou o limite de 50% sobre o valor atualizado do contrato, conforme artigo 65 da Lei de Licitações. EPP0 SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA e JOSÉ CARLOS VENTRI também contestaram (pgs.1628/1659). Afirmam inexistir dolo, ilegalidade ou má fé a justificar a pretensão sancionatória. Aduzem preliminar de ilegitimidade passiva do requerido, José Carlos, que não pode ser responsabilizado pelos atos praticados pela pessoa jurídica. Sustentam a regularidade do procedimento licitatório, refutam a tese da existência de conluio prévio ao certame, ao qual compareceram sete empresas, das quais quatro foram habilitadas, tendo a requerida apresentado a proposta com melhor preço. Argumenta que o fracionamento da licitação acarretaria perdas de escala, que a aglutinação dos objetos sequer foi repreendida pela Tribunal de Contas, que não houve irregularidades na execução do contrato, que os acréscimos ocorridos estão no limite do que autoriza o artigo 65 da lei 8666/93, que os desembolos ocorreram

conforme as medições, mediante apresentação de nota fiscal/fatura. Refutam a assertiva de que houve "jogo de planilhas" ou de que agiram com dolo e postulam pela integral improcedência da ação.

Houve réplica (pgs.1666).

Na fase de especificação de provas, o Ministério Público entendeu suficientes os documentos juntados. EPP0 SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS e JOSÉ CARLOS VENTRI pugnaram pela produção de prova técnica simplificada e prova oral, além da apresentação de prova documental, ao passo que MARILDA CORTIJO e outros protestaram somente pela prova oral (pgs.1671, pgs.1674/1681, pgs.1682).

Saneamento, análise das preliminares e dos pedidos de provas (pgs.1683).

Realizada audiência de instrução e julgamento (pgs.1753/1754), as partes apresentaram alegações finais (pgs.1755/1779, pgs.1798/1828, pgs.1832/1869).

Com a entrada em vigor da Lei 14.230/2021, os requeridos suscitarão a análise de questões preliminares (pgs.1870/1892). Houve nova manifestação do Ministério Público (pgs.1898/1901) e os autos tornaram conclusos.

É o relatório.

Decido.

Das questões preliminares.

Postulam os requeridos pela declaração da prescrição, com base no art. 23 da Lei nº 8.429/92, com a redação dada pela Lei nº 14.230/21.

A Lei nº 14.230/21 modificou consideravelmente a Lei nº 8.429/92, sendo oportuno transcrever a integralidade da redação atual do art. 23, que disciplina a prescrição da pretensão sancionadora em relação às sanções decorrentes dos atos de improbidade administrativa:

"Art. 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência. I - (revogado); II - (revogado); III - (revogado).

§ 1º A instauração de inquérito civil ou de processo administrativo para apuração dos ilícitos referidos nesta Lei suspende o curso do prazo prescricional por, no máximo, 180 (cento e oitenta) dias corridos, recomeçando a correr após a sua conclusão ou, caso não concluído o processo, esgotado o prazo de suspensão.

§ 2º O inquérito civil para apuração do ato de improbidade será concluído no prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos, prorrogável uma única vez por igual período, mediante ato fundamentado submetido à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica.

§ 3º Encerrado o prazo previsto no § 2º deste artigo, a ação deverá ser proposta no prazo de 30 (trinta) dias, se não for caso de arquivamento do inquérito civil.

§ 4º O prazo da prescrição referido no caput deste artigo interrompe-se:

I - pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa;

II - pela publicação da sentença condenatória;

III - pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência;

IV - pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência;

V - pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência.

§ 5º Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no 'caput' deste artigo.

§ 6º A suspensão e a interrupção da prescrição produzem efeitos relativamente a todos os que concorreram para a prática do ato de improbidade.

§ 7º Nos atos de improbidade conexos que sejam objeto do mesmo processo, a suspensão e a interrupção relativas a qualquer deles estendem-se aos demais.

§ 8º O juiz ou o tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá, de ofício ou a requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato, caso, entre os marcos interruptivos referidos no § 4º, transcorra o prazo previsto no § 5º deste artigo" .

No caso em comento, o processo licitatório para a contratação de empresa para execução de obras de reforma e ampliação de cinco escolas municipais foi deflagrado em outubro de 2008, concluído no mês de dezembro do mesmo ano, seguindo-se a adjudicação de seu objeto e a formalização do contrato administrativo n.02/2009 em janeiro de 2009.

Nesse cenário, considerando que a presente ação foi proposta em 29 de novembro de 2016, forçoso concluir que, na data da distribuição, ainda não se escoara o prazo de 08 anos, previsto na nova lei, contado da data da conclusão da licitação e formalização do contrato administrativo, em janeiro e dezembro de 2009. Bem por isso, rejeita-se a preliminar de prescrição.

Prosseguindo, de acordo com o disposto no parágrafo 4º do dispositivo legal, o ajuizamento da ação interrompe o decurso do prazo prescricional, a partir de quando recomeça a correr, pela metade do prazo previsto no 'caput' (§ 5º).

Na situação em análise, a considerar a postura na novel legislação, a interrupção do prazo prescricional, conforme o art. 23, § 4º, I, da Lei nº 8.429/92, ocorreu há mais de quatro anos, sem que tenha havido a publicação da sentença condenatória. Contudo, não se desconhece a polêmica jurisprudencial acerca da aplicabilidade imediata das disposições da novel legislação, tema em franco debate doutrinário e jurisprudencial.

Sobre o assunto, convém trazer à colação o seguinte julgado, adotando entendimento ao qual me filio, notadamente porque não se trata de norma de direito penal, mas de ilícito administrativo.

"Entendo que não ocorre a retroação da Lei 14230/21, que deu nova redação a diversos artigos da Lei nº 8.429/92, como pretende o ora embargante, pois a conduta descrita como ímproba nos presentes autos ocorreu quando ainda não vigente esse novo dispositivo legal. Ora, conquanto a nova lei exija pronta aplicação de seus dispositivos processuais, na forma do art. 14 do Código de Processo Civil, o mais trazido por ela, ou seja, em assuntos de direito material, não há essa aplicação por força do art. 5º, caput, XL, da Constituição Federal, o § 4º do art. 1º da Lei 8.429/92, com a nova redação, e mesmo o art. 6º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), pois não cuidam da chamada novatio legis in melius, a exigir pronta e imediata aplicação para situações ímprobas acontecidas antes dessa nova circunstância legal. A ação em que se pretende a condenação por ato de improbidade administrativa possui índole civil, administrativa. Não possui caráter penal. Lembre-se que o art. 5º., inciso XL do art. 5º da Constituição Federal prevê que "a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu". Ora, tal dispositivo constitucional se restringe à lei penal. Os campos da ação de improbidade administrativa e os da lei penal são diversos, tanto que o art. 37 parágrafo 4º., da CF prevê que: "os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Se aquele apontado como tendo praticado ato ímprobo responde civil-administrativamente e também criminalmente, é fácil perceber que as esferas da improbidade administrativa civil e criminal são diversas e não podem ser confundidas. Ademais, os princípios mencionados no art. 1º., parágrafo 4º., da LIA, com a nova redação trazida pela Lei 14.230/2021 devem ser aplicados em prol da administração, da sociedade, não sendo o caso de aplicação visando o favorecimento privado dos requeridos da demanda. Não se pode atribuir a natureza de pena (criminal) para as penalidades previstas na LIA, de modo que não é possível pretender aplicar de forma retroativa dos dispositivos de natureza material, trazidos pela Lei 14.230/2021 (Embargos de Declaração Cível nº 1006538-82.2018.8.26.0152/50002).

No mesmo sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Improbidade Administrativa Retroação de lei nova - Omissões e contradições - Pretensão de rediscussão do mérito do processo Impossibilidade: - O princípio da retroatividade da lei nova mais benéfica não se aplica às penalidades por improbidade administrativa. - Ausente omissões, contradições, obscuridades e erros materiais." (TJSP; Embargos de Declaração Cível 1003043-67.2017.8.26.0248; Relator (a): Teresa Ramos Marques; Órgão Julgador: 10ª Câmara de

Direito Público; Foro de Indaiatuba - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/02/2022; Data de Registro: 14/02/2022)

"Embargos de declaração. Descabimento. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Fato fora da vigência da Lei 14.230/21. Embargos rejeitados." (TJSP; Embargos de Declaração Cível 2234708-29.2021.8.26.0000; Relator (a): Borelli Thomaz; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro de Cabreúva - Vara Única; Data do Julgamento: 07/02/2022; Embargos de Declaração Cível nº 1006538-82.2018.8.26.0152/50002, Registro: 07/02/2022)

A propósito, significativa, porque juridicamente forte a fundamentação, indicar precedente do E. Tribunal de Justiça, sob relatoria do Desembargador CARLOS VON ADAMEK:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO Impossibilidade, a princípio, de aplicação retroativa da Lei nº 14.230/21, visto que ela não contém previsão nesse sentido Inteligência do art. 6º da LINDB Sem olvidar a polêmica no C. STJ acerca da possibilidade de retroatividade da lei mais benéfica em se tratando de direito administrativo sancionador, mesmo que adotada a posição que admite a aplicação retroativa da Lei nº 14.230/21, é certo que não verificada a prescrição intercorrente Mesmo após a edição da Lei nº 14.230/21, permanece aplicável o entendimento firmado pelo E. STF no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 897, vez que calcado em norma constitucional (art. 37, § 5º, da CF), logo, prevalecente sobre norma infraconstitucional (art. 23 da Lei nº 8.429/92, com a redação dada pela Lei nº 14.230/21) A ausência de distinção entre o referido precedente vinculante e o presente caso torna inviável o acolhimento da tutela pleiteada. Inteligência do art. 927, III e § 1º e 489, § 1º, VI, ambos do CPC/15. A aplicação analógica da Súmula nº 383 do STF ao caso em tela a fim de preencher a lacuna aberta pela Lei nº 14.230/21, conforme autorização legal contida no art. 4º da LINDB, também afasta a verificação da prescrição intercorrente, mormente em homenagem ao princípio constitucional da proibição da proteção insuficiente, a fim de evitar a nulidade prevista no § 10-F, II do art. 17 da Lei nº 8.429/92, incluído pela Lei nº 14.230/21 (mantendo-se, pois, a designação de audiência de instrução e julgamento para a produção da prova oral, atendendo, inclusive ao pedido dos próprios agravantes deduzido ao r. Juízo 'a quo'), e diante do disposto no art. 206-A do Código Civil Decisão mantida Recurso desprovido. (Agravado de Instrumento 2264638-92.2021.8.26.0000; 2ª Câmara de Direito Público; Data de Registro: 27/01/2022).

Em suma, no caso em comento, o novo prazo de prescrição intercorrente da pretensão punitiva, no que tange às cominações próprias dos atos de improbidade (artigo 12, inciso II, da Lei 8.492/92), não se aplica de forma retroativa, passando a vigorar a contar da data da entrada em vigor da novel legislação, respeitados, portanto, os atos processuais até então praticados. Rejeita-se, portanto, a preliminar de prescrição intercorrente.

Ademais, sobre a imprescritibilidade do ressarcimento de dano ao erário, não é demais ressaltar que o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese jurídica, em julgamento do Tema de Repercussão Geral (nº 897):

"São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa".

O Superior Tribunal de Justiça, aos 22/9/2021, na linha do decidido pela Suprema Corte (Tema 897), ainda antes das modificações ocorridas na LIA, veio de definir tese, em sede de recursos repetitivos (Tema 1.089), segundo a qual "'Na ação civil pública por ato de improbidade administrativa é possível o prosseguimento da demanda para pleitear o ressarcimento do dano ao erário, ainda que sejam declaradas prescritas as demais sanções previstas no art. 12 da Lei 8.429/92'".

Do mérito propriamente dito.

Fazendo-se um apanhado geral da doutrina acerca do tema, a improbidade administrativa pode ser conceituada como o exercício da função pública de forma ilegal e imoral, para se obter enriquecimento ilícito, causar dano ao erário ou simplesmente violar os princípios gerais da administração pública.

Nesse sentido:"(...) a corrupção administrativa, que, sob diversas formas, promove

o desvirtuamento da Administração Pública e afronta os princípios nucleares da ordem jurídica (Estado de Direito, Democrático e Republicano) revelando-se pela obtenção de vantagens patrimoniais indevidas às expensas do erário, pelo exercício nocivo das funções e empregos públicos, pelo "tráfico de influência" nas esferas da Administração Pública e pelo favorecimento de poucos em detrimento dos interesses da sociedade, mediante a concessão de obséquios e privilégios ilícitos. (PAZZAGLINI FILHO, Marino; ELIAS ROSA, Márcio Fernando e FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Improbidade Administrativa, Editora Atlas, 1996, pág. 35).

Enfim, a improbidade administrativa é a prática, pelo agente público, de um ato de forma contrária aos ditames da honestidade e da boa-fé. A imoralidade constitui pressuposto para a caracterização da improbidade administrativa. É uma ilegalidade qualificada.

Estabelecidas tais premissas, por meio da presente ação civil pública, o Ministério Público do Estado de São Paulo imputa aos requeridos a prática de atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário (artigos 10 e 11 da Lei 8.429/92) e que atentam contra os princípios da administração pública, com aplicação das sanções previstas no do art. 12 da mesma legislação.

Em síntese, narra a petição inicial que, em outubro de 2008, a Secretaria Municipal de Educação, da Estância Turística de Itu, por sua então secretária, MARILDA CORTIJO, deflagrou processo licitatório para a contratação de empresa para a execução de obras de reforma e ampliação de cinco escolas da rede pública, a saber, EMEF Olga Benário, EE Cidade Nova - Marilze Calil, EMEF Prof. Cid Rocha, EMEF Profª Aparecida Beatriz Cristofoleti Pionti e EMEF Prof. Firmino do Espírito Santo Jr.. A licitação foi realizada na modalidade concorrência pública, tipo menor preço, conforme edital de abertura. Compareceram ao local das obras e retiraram a minuta do edital trinta e um potenciais licitantes, dos quais apenas sete participaram da licitação, sendo três inabilitados.

Ato contínuo, foram abertas as propostas de preços de quatro empresas, sagrando-se vencedora a requerida, EPP0 SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS, com proposta global de R\$2.020.862,26, celebrado contrato administrativo n.02/2009, em janeiro de 2009, com previsão de 6 meses para a conclusão das obras de reforma/ampliação.

LUIZ CARLOS LOURENCETTI, então Secretário do Planejamento do Município, foi designado para gerir o contrato, sob orientação da Secretária da Educação, MARILDA CORTIJO.

As obras foram concluídas depois de dez meses, com três prorrogações para a finalização dos serviços e dois aditamentos de preços, o que elevou o preço final em 48,9% do valor originariamente previsto.

Submetidos ao crivo do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a licitação e o contrato, com os sucessivos aditamentos, foram julgados irregulares. Pois bem.

Segundo o Ministério Público, não houve planejamento para a execução das obras. Além disso, houve o direcionamento do certame em favor da empresa contratada e prorrogações irregulares, que acarretaram prejuízo aos cofres públicos. Isso porque os projetos de reforma ou de ampliação não contemplavam as reais necessidades das escolas, que poderiam ter sido indicadas pelos respectivos diretores, se questionados a respeito. Consequência disso foram as diversas readequações realizadas no curso da execução das obras, desprezando-se materiais que constavam dos orçamentos apresentados pelos concorrentes, e utilizando-se quantidade superior à estimada para outros materiais.

Ainda, no entender do Ministério Público, ocorreu indevida aglutinação de objetos e limitação à concorrência. Aponta que seria muito mais vantajoso ao Município licitar separadamente as obras para cada uma das cinco escolas. Além disso, o prazo exíguo, as exigências de capacidade técnica e o recolhimento da garantia da proposta sob percentual global, como condição para participação do certamente, além da exigência de capital mínimo, limitou demasiadamente a participação de outras empresas e não trouxe benefício ao erário.

No entanto, ao cabo da instrução, não se vê dolo específico no sentido de direcionar a licitação a uma empresa determinada, nem tampouco está claro que a aglutinação dos objetos tenha acarretado prejuízo ao erário.

Acompanham a inicial os projetos de reforma/ampliação de cada uma das cinco escolas, acompanhados dos respectivos orçamentos (pgs.69/150), tudo amparado em estudo prévio realizado por empresa contratada pelo Município (Ricco Engenharia). Consta, ainda, o edital de licitação, elaborado com base no estudo realizado, para a contratação de empresa destinada a executar as obras nas escolas (pgs.151/169), incluída a execução, o fornecimento de materiais, mão de obra e serviços complementares.

De início, trinta empresas interessadas procederam à visita técnica no local das obras (pgs.255/261), das quais sete participaram da solenidade de recebimento de envelopes "documentação" e proposta comercial (pgs.262) e quatro foram habilitadas (pgs.263/264). A princípio, as empresas não habilitadas foram excluídas do certame por questões técnicas não relacionadas com a aglutinação das reformas numa única concorrência pública (Pgs.263/264).

A requerida, EPP0 Saneamento Ambiental e Obras, apresentou proposta global de R\$2.020.862,26 (Pgs.265/290), especificando materiais, serviços e mão de obra para cada escola. Na mesma linha, as demais empresas habilitadas apresentaram suas propostas.

Segundo se vê, os preços globais apresentados eram muito semelhantes (pgs.380/381), fato que indica que foram baseados em dados reais do mercado e condizentes com os projetos relativos a cada escola.

Ademais, não consta que as demais empresas habilitadas tenham se insurgido em face de qualquer item do edital, dos projetos de reforma das escolas ou em face da proposta apresentada pela empresa vencedora do certame.

Não há, no caso, indício de manipulação de orçamento ou de direcionamento do certame a uma empresa determinada. Não há elementos técnicos que, concretamente, autorizem concluir que não houve observação da melhor proposta, ou que seria mais proveitoso para a Administração Pública se não houvesse a aglutinação das reformas num único certame.

Com efeito, muito embora plausível a tese de que a aglutinação de objetos não seria, no caso concreto, a melhor estratégia para a licitação das obras das cinco escolas municipais, as quais apresentavam algumas características específicas, não ficou efetivamente demonstrado que o certame único tenha causado efetivo prejuízo para a Administração.

Há elementos indicativos de que a realização de licitações separadas poderia ter ampliado o espectro de interessados na concorrência. No entanto, a aglutinação de objetos, por si só, não é ilegal e não impediu que, além da vencedora da licitação, outras três empresas alcançassem a fase final do certame, uma vez que atenderam às exigências técnicas incluídas no edital.

Por outro lado, mostra-se também plausível a tese segundo a qual a aglutinação de objetos propicia a aquisição de materiais em escala e a contratação de mão de obra e de serviços em melhores condições.

Os fatos relatados, à vista das provas juntadas, não configuram improbidade administrativa. A realização do certame de forma aglutinada não infringiu dispositivo legal e não é claro que tenha causado prejuízo à Administração, muito menos há elementos que conduzam à conclusão inequívoca de que houve direcionamento doloso à empresa vencedora.

Não há como concluir, extreme de dúvidas, que a aglutinação de objetos, a garantia exigida e as exigências inseridas no edital foram motivadas pela intenção predeterminada de conduzir a êxito a requerida, EPP0 SANEAMENTO, restringindo a ampla competitividade e causando efetivo prejuízo ao erário.

Sem que haja a comprovação de efetiva fraude à licitação, não se presume a ocorrência de dano ou de efetivo direcionamento, por meras suposições.

"É sabido que a Lei de Improbidade constitui o principal instrumento jurídico de combate à corrupção, desonestidade e má-fé na gestão da coisa pública. Prevê sanções políticas, administrativas e civis aplicáveis, de forma cumulativa, parcial ou isolada, ao administrador público, que, no desempenho de suas atribuições funcionais, praticar ato de improbidade administrativa que implique enriquecimento ilícito próprio ou de terceiros, que ocasione prejuízo efetivo ao erário ou que atente contra os princípios norteadores da Administração Pública. Enquanto o termo

"probidade" significa integridade, honestidade, retidão; "improbidade", por sua vez, traduz-se como ausência de honradez, desonestidade. A improbidade pressupõe sempre um desvio ético na conduta do agente, a transgressão consciente de um preceito de observância obrigatória. Daí o elemento subjetivo é indispensável para a caracterização do ato ímprobo." (Apelação Cível nº 1001925-20.2017.8.26.0066). A outra questão levantada pelo Ministério Público diz respeito a irregularidades praticadas quando da execução do contrato, especificamente, prorrogação e atrasos nas obras.

O Contrato n. 02/2009 (pgs.383/392) previa a conclusão dos trabalhos no prazo de 06 (seis) meses (cláusula 1.1).

Não se disputa que houve aditivo ao contrato originário, haja vista a prorrogação do prazo para conclusão das obras, com base em justificativas de ordem técnica apresentadas. No entanto, decorre da prova documental que a prorrogação foi justificada, em consonância com o previsto no artigo 57 da Lei de Licitações, e contou com a aprovação do gestor do contrato e da Assessoria Jurídica do Município. Nesse sentido, o teor do documento acostado às pgs.678/699, indicando que as duas prorrogações solicitadas atendiam aos interesses da Administração e estavam em consonância com o princípio da eficiência.

Os documentos de pgs.699/700, pgs.732/737 e pgs.743/763, especificam a necessidade de prorrogação para melhor adequação das salas de aula, salas de professores, salas de reuniões e estrutura administrativa, resultado de discussão com engenheiro e arquiteto da contratada, prefeitura, gestor contratual e diretores das escolas (planilhas de pgs.701/719).

A despeito das irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado (pgs.781/799), o fato é que, em juízo, pouco se demonstrou a respeito das apontadas ilicitudes, no que tange ao certame e à fase de execução.

Para tal finalidade, a prova documental juntada com a petição inicial, embora suficiente a deflagrar a instauração da demanda, não fornece elementos para, isoladamente, e sem a necessária complementação, inclusive de ordem técnica, autorizar o édito condenatório.

A tese da ocorrência de "jogo de planilhas" e de prejuízo ao erário, embora plausível a princípio, não ficou suficientemente demonstrada. No curso da demanda, em juízo, não houve suficiente esclarecimento a respeito, nem as partes demonstram interesse no elastério probatório.

Acrescente-se, outrossim, não ter sido extrapolado o limite de 50%, estipulado no artigo 65, parágrafo 1º, da Lei 8666.93.

Bem por isso, a tese do prejuízo ao erário carecia de melhor demonstração.

Não há prova de que, no redimensionamento/readequação dos projetos, tenha ocorrido superfaturamento ou inexecução das alterações propostas e convalidadas. As três prorrogações concedidas, via aditivo contratual, e alterações do projeto inicial, foram justificadas e acompanhadas pela administração.

A prova documental não autoriza concluir que, a par das alterações implementadas, houve desvio de recursos, superfaturamento de materiais ou prejuízo ao erário decorrente de inexecução ou de execução parcial das obras.

Com efeito, não se vê o elemento subjetivo essencial à configuração da improbidade, tampouco restou demonstrada a ocorrência de dano efetivo à Administração.

Sobre o tema, há disposição da lei específica que autoriza a prorrogação do prazo originalmente pactuado:

"Art. 57, incisos I e II, e parágrafos da Lei 8.666/93. (...)

§ 1º.Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

I -alteração do projeto ou especificações, pela Administração;

II -superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato; (...)

§ 2º.Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato. (...)."

A Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 8.666/93) autoriza a alteração unilateral

do contrato administrativo quando houver necessidade de modificação do projeto para melhor adequação técnica aos seus objetivos (artigo 65, §1º, inciso I, alínea "a"33).

Ao que parece, foi exatamente isso que ocorreu no caso concreto.

As testemunhas ouvidas prestaram esclarecimentos a esse respeito.

Gustavo Adolfo Diniz, funcionário da requerida, EPP0 Saneamento Ambiental, esclareceu que os acréscimos e decréscimos de serviços em obras, tais como os que ocorreram no caso, são habituais e ocorrem, via de regra, por conta da realidade encontrada no caso concreto. São regulares os ajustes, especialmente em se tratando de reformas e ampliações, como se deu no caso em análise, em que a realidade encontrada in locu, impôs adaptações do projeto e algumas alterações. Citou, ao analisar as onze medições realizadas ao longo da obra, que houve algumas alterações concernentes a serviços de fundação das escolas e instalações elétricas, em consonância com o que ocorre em obras de reforma em geral, tendo sido excluídos alguns serviços que se revelaram desnecessários.

O depoente também esclareceu que, via de regra, a aglutinação de objetos é vantajosa em termos orçamentários, por força do ganho de escala, e do controle da administração.

Luiz Carlos Vieira era diretor de uma das escolas ampliadas. Afirmou que houve algumas dificuldades ao longo da execução, que se deu de forma concomitante às aulas. Esclareceu que, durante os trabalhos, foi constatado um desnível da escola em relação à rua, o que demandou adaptação, e afirmou que os serviços foram finalizados, embora com algum atraso, e melhoraram muito a estrutura do estabelecimento de ensino público municipal. Afirmou ter havido melhora significativa do prédio, que atendeu ao reclamo do diretor e às necessidades de alunos e professores. Esclareceu que, antes da ampliação, o prédio da escola era bastante acanhado e, depois de ampliado, passou a atender a expectativa de professores e alunos.

Em suma, se das modificações dos projetos originais decorreu alguma irregularidade, esta não pode ser reconhecida como improbidade administrativa, dada a inexistência de prova de que os gestores públicos agiram de má-fé, imbuídos de qualquer intenção espúria, voltada ao não atendimento do interesse público primário e das finalidades de ampliar e melhorar o espaço das escolas municipais.

Impõe-se considerar, por fim, que os serviços contratados foram prestados, as obras de ampliação e reforma foram integralmente finalizadas e entregues.

Por todo o exposto, o cenário fático probatório não é suficiente para a configuração de ato de improbidade e deve conduzir à integral improcedência do feito.

Posto isso, julgo IMPROCEDENTE a presente demanda movida por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios inexistentes, nos termos do artigo 18 da Lei nº 7.347/85 e RT 729/202 e JTJ 175/90.

P.R.I.C.

Itu, 18 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA